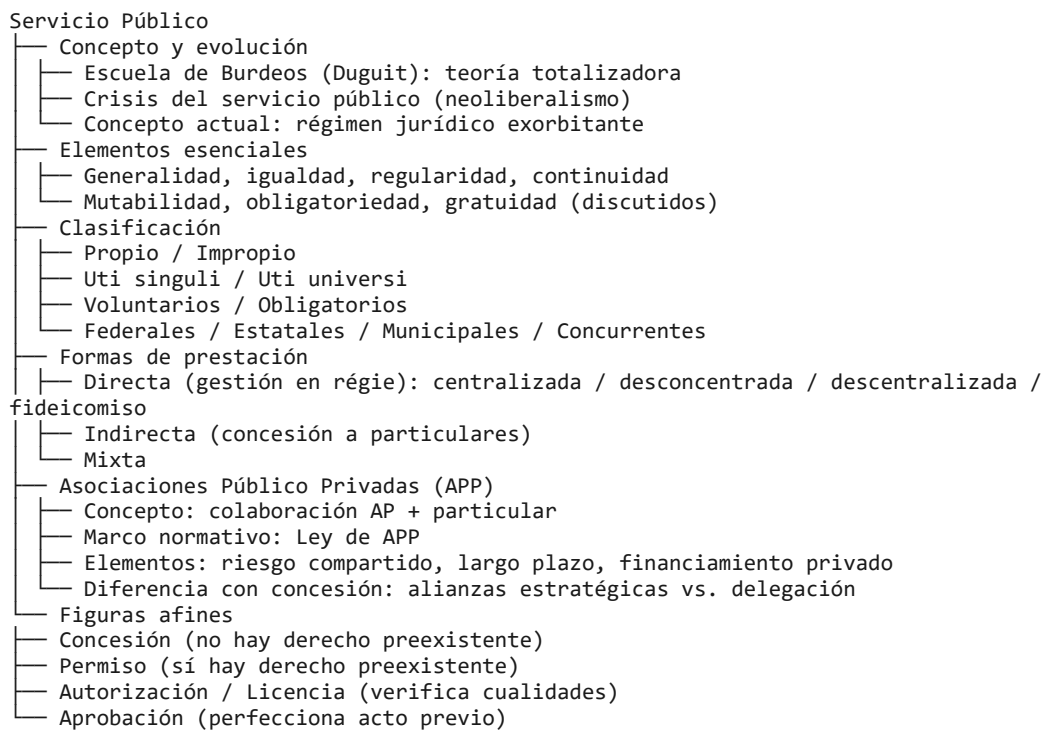


UNIDAD 9. EL SERVICIO PÚBLICO Y LA CONCESIÓN

UNIDAD 9

EL SERVICIO PÚBLICO Y LA CONCESIÓN

Mapa conceptual



Objetivos de aprendizaje

- **Comprender:** el concepto de servicio público, su evolución histórica y las distintas posturas doctrinales sobre su naturaleza jurídica.
- **Identificar:** los elementos esenciales del servicio público y distinguir entre servicio público propio e impropio.

- **Analizar:** las diversas formas de prestación de los servicios públicos y sus implicaciones jurídicas.
- **Distinguir:** la concesión administrativa del permiso, la autorización y la licencia.
- **Explicar:** el régimen jurídico de la concesión de servicio público: concepto, naturaleza, elementos, procedimiento, derechos, obligaciones y causas de extinción.
- **Evaluar:** críticamente la crisis del servicio público frente al neoliberalismo.
- **Distinguir:** las Asociaciones Público Privadas de la concesión tradicional, identificando su marco normativo y elementos esenciales.
- **Aplicar:** el marco normativo (artículo 28 CPEUM y legislación secundaria) a casos concretos.

Competencias a desarrollar

- **Análisis jurídico:** Capacidad para identificar cuándo una actividad constituye servicio público propio y cuándo es una actividad privada regulada.
- **Argumentación jurídica:** Habilidad para sostener razonadamente la naturaleza jurídica de la concesión como acto unilateral.
- **Resolución de casos:** Aptitud para analizar controversias sobre prestación de servicios públicos y concesiones.
- **Redacción administrativa:** Competencia para elaborar escritos relacionados con solicitudes de concesión, permisos y autorizaciones.

Concepto y evolución del servicio público

La escuela de Burdeos y la teoría totalizadora

El servicio público es uno de los conceptos fundamentales del derecho administrativo. Su construcción doctrinal se atribuye principalmente a **Léon Duguit**, quien a principios del siglo XX propuso una visión totalizadora: el Estado no era más que un conjunto de servicios públicos (Roldán Xopa, Cap. X, p. 2). Para Duguit, servicio público era «toda actividad que deba ser asegurada, reglada y controlada por los gobernantes».

Gaston Jeze amplió aún más el concepto al considerar que servicio público era «toda actividad de la administración pública», mientras que **Maurice Hauriou** restringió el concepto a «una parte de la actividad de la administración pública» (Fernández Ruiz, INEHRM, Cap. XIII, p. 146).

Crisis y transformación del servicio público

A partir de la segunda mitad del siglo XX, el modelo del Estado social e intervencionista comenzó a retroceder frente al avance del neoliberalismo. Autores como **Gaspar Ariño Ortiz** llegaron a sostener que el servicio público había «completado su ciclo» y debía ser abandonado como categoría jurídica.

Roldán Xopa propone un enfoque distinto: el servicio público no es tanto una actividad como el régimen jurídico de una actividad, es decir, «una técnica de regulación» (Roldán Xopa, Cap. X, p. 5).

Concepto actual

Definición: Definición

La doctrina mexicana actual ha alcanzado cierto consenso en torno a la definición de **Jorge Fernández Ruiz**: «Servicio público es toda actividad técnica destinada a satisfacer una necesidad de carácter

general, cuyo cumplimiento uniforme y continuo deba ser permanentemente asegurado, reglado y controlado por los gobernantes, con sujeción a un mutable régimen jurídico exorbitante del derecho privado, ya por medio de la Administración pública, bien mediante particulares facultados para ello por autoridad competente, en beneficio indiscriminado de toda persona» (Fernández Ruiz, INEHRM, Cap. XIII, p. 148).

Para que una actividad pueda ser calificada como servicio público se requiere una **reserva de ley**: el Congreso de la Unión, mediante ley, debe considerar que esa actividad es originaria del Estado conforme a la Constitución (artículo 28 constitucional) (Hamdan, Tema XIII, p. 175).

Elementos esenciales del servicio público

Existe consenso doctrinal en que los elementos esenciales son cuatro: **generalidad, igualdad, regularidad y continuidad** (Fernández Ruiz, INEHRM, Cap. XIII, p. 150; Martínez Morales, 2o Curso, Tema XIII; Hamdan, Tema XIII, p. 176).

- **Generalidad:** El servicio debe estar al alcance de todas las personas que lo requieran.
- **Igualdad:** Todos los usuarios deben recibir el mismo trato en condiciones equivalentes.
- **Regularidad:** El servicio debe prestarse conforme a las reglas y normas preestablecidas.
- **Continuidad:** El servicio no puede interrumpirse, salvo causas de fuerza mayor.

Además, ciertos autores discuten otros caracteres: **obligatoriedad, adaptabilidad o mutabilidad, permanencia y gratuidad**.

Clasificación de los servicios públicos

a) Por su reconocimiento jurídico:

- **Servicio público propio:** Creado por ley y atribuido al Estado.
- **Servicio público impropio:** Deriva de un permiso, licencia o autorización administrativa.

b) Por las características del usuario:

- **Uti singuli:** A usuarios determinados (agua potable, energía eléctrica).
- **Uti universi:** Beneficia a la colectividad indeterminada (alumbrado público).

c) Por su forma de exigibilidad:

- **Voluntarios:** Solo se prestan a quien los solicita, conforme a la demanda del usuario.
- **Obligatorios:** El usuario está obligado constitucional o legalmente a recibirlos (por ejemplo, la educación pública obligatoria).

d) Por la jurisdicción territorial:

- **Federales:** Competencia de la Federación.
- **Estatales:** Competencia de las entidades federativas.
- **Municipales:** Artículo 115, fracción III CPEUM.
- **Concurrentes:** Competencia compartida.

Formas de prestación de los servicios públicos

Prestación directa (gestión en régie)

Modalidades: mediante dependencia centralizada, órgano desconcentrado, organismo público descentralizado o fideicomiso público.

Prestación por particulares

El artículo 28 de la CPEUM autoriza al Estado a concesionar la prestación de servicios públicos. Los particulares pueden prestar servicios públicos bajo el régimen de **concesión**.

Prestación mixta

Roldán Xopa identifica cinco modalidades: prestación por el Estado en condiciones monopólicas; por particulares en monopolio natural; por particulares en monopolio regulatorio; por el Estado en competencia con particulares; y por el Estado en segmentos que el mercado no cubra.

La concesión administrativa: concepto, naturaleza y elementos

Concepto

Definición: Definición

Gabino Fraga define la concesión como «el acto administrativo por el cual se otorga al particular el derecho de manejar y explotar un servicio público o la explotación y aprovechamiento de bienes del dominio público del Estado».

Definición: Definición

El Diccionario de Rafael Martínez proporciona una definición completa: «Concesión es el acto jurídico unilateral por el cual el Estado confiere a un particular la potestad de explotar a su nombre un servicio o bien públicos, que le pertenecen a aquél, satisfaciendo necesidades de interés general» (Martínez Morales, Diccionario, voz «Concesión»).

Naturaleza jurídica

Existen tres teorías principales: a) **Teoría contractual**: Sostiene que la concesión es un contrato entre el Estado y el particular. b) **Teoría del acto administrativo unilateral (o reglamentaria)**: Sostiene que es un acto administrativo unilateral. Es la tesis que impera en México (Hamdan, Tema XIII, p. 178). c) **Teoría mixta**: Combina elementos de ambas naturalezas.

En México, la doctrina mayoritaria la considera un acto mixto con predominio de la naturaleza reglamentaria (Fernández Ruiz, INEHRM, Cap. XIII, p. 160). La concesión es además **intuitu personae**.

Elementos de la concesión

Sujeto concedente, concesionario, usuario, objeto (el servicio público o bien de dominio público), título de concesión y plazo.

Procedimiento de otorgamiento

Convocatoria pública → licitación pública → evaluación de propuestas (idoneidad) → otorgamiento → publicación en el DOF.

Derechos y obligaciones del concesionario

Derechos: Prestar el servicio y percibir la tarifa; estabilidad del título durante el plazo; uso de los bienes afectos al servicio.

Obligaciones: Prestar el servicio conforme al título y la ley; mantener continuidad, regularidad, igualdad y generalidad; someter tarifas a aprobación; permitir inspección y vigilancia; no suspender el servicio unilateralmente.

Extinción de la concesión

Vencimiento del plazo, revocación por interés público (con indemnización), caducidad por incumplimiento grave (sin indemnización), renuncia, muerte o incapacidad del concesionario, nulidad.

El permiso, la autorización y la licencia

La doctrina distingue entre concesión, permiso, autorización y licencia con base en la existencia o no de un derecho preexistente del particular:

- **Concesión:** No existe derecho preexistente.
- **Permiso, autorización o licencia:** Existe un derecho preexistente cuyo ejercicio está sujeto a control administrativo.

Martínez Morales propone la siguiente delimitación:

- **Aprobación:** Para perfeccionar un acto previo.
- **Autorización:** Para conferir validez a un derecho.
- **Permiso:** Para facilitar el uso de bienes del Estado.
- **Licencia:** Para aceptar la realización de actividades previa verificación de conocimientos.

Las Asociaciones Público Privadas (APP)

Concepto y origen

Las Asociaciones Público Privadas (APP) son un esquema de colaboración de largo plazo entre el sector público y el sector privado para la prestación de servicios públicos, desarrollo de infraestructura o realización de proyectos de interés general. A diferencia de la concesión tradicional —donde el Estado delega una actividad que le es propia—, en la APP ambas partes comparten riesgos, recursos y responsabilidades bajo una estructura contractual más flexible y equilibrada.

El origen del modelo APP se remonta al *Private Finance Initiative* (PFI) del Reino Unido en los años noventa y se ha expandido globalmente como respuesta a la limitación de recursos públicos para financiar grandes proyectos.

Marco normativo en México

En México, las APP se rigen principalmente por la **Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP)**, publicada el 16 de enero de 2012, y su Reglamento. Esta ley establece:

- **Objeto:** Regular los esquemas de APP en los que participan entidades del sector público y del sector privado para desarrollar proyectos que generen valor social.
- **Ámbito de aplicación:** Entidades de la Administración Pública Federal conforme a la propia ley.
- **Requisitos del proyecto:** Viabilidad técnica, legal, ambiental, económica y social; análisis de valor por dinero (*value for money*); estructura de riesgos.

También existen disposiciones aplicables en materia de APP en la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados (LOPSRM)** y la **Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público**.

Elementos esenciales de la APP

1. **Largo plazo:** Generalmente superan los 10 años y pueden llegar a 30-40 años.
2. **Riesgo compartido:** A diferencia de la obra pública tradicional o la concesión pura, los riesgos se distribuyen entre el sector público y el privado según quién esté en mejor posición para gestionarlos.
3. **Financiamiento privado:** El particular aporta total o parcialmente el capital necesario para el proyecto.
4. **Vinculación de pago a desempeño:** La contraprestación que recibe el particular —pública, tarifaria o mixta— depende del cumplimiento de indicadores de calidad y disponibilidad del servicio.
5. **Reversión de activos:** Al término del contrato, los bienes afectos al proyecto revierten al Estado.

Diferencia entre APP y concesión tradicional

Elemento	Concesión tradicional	APP
Naturaleza jurídica	Acto administrativo unilateral mayoritariamente	Contrato de largo plazo
Riesgo	Principalmente a cargo del concesionario	Compartido público-privado
Financiamiento	Generalmente privado	Privado con posible apoyo público
Marco normativo	Leyes sectoriales (aguas, carreteras, etc.)	LAPP y legislación sectorial
Retribución	Tarifas de usuarios	Pago público, tarifario o mixto vinculado a desempeño
Plazo	Variable (15-30 años típicamente)	Largo plazo (20-40 años)
Régimen de bienes	Bienes afectos al servicio	Reversión al Estado al término

Procedimiento de APP

1. **Identificación y registro** del proyecto en la cartera de proyectos APP.
2. **Estudios de viabilidad** (técnica, legal, ambiental, social, económica y financiera).
3. **Análisis de valor por dinero:** Demostrar que el esquema APP es más eficiente que la obra pública tradicional.
4. **Estructuración del proyecto** y asignación de riesgos.
5. **Licitación pública** (convocatoria, bases, evaluación, fallo).
6. **Firma del contrato de APP** y publicación.
7. **Ejecución, supervisión y evaluación** durante toda la vigencia del proyecto.

Ventajas y riesgos de las APP

Ventajas: Movilización de capital privado, transferencia de riesgos al sector privado, eficiencia en ejecución y operación, innovación tecnológica, liberación de recursos públicos para otras prioridades.

Riesgos: Complejidad contractual, compromisos fiscales de largo plazo, posibles sobrecostos si la estructura de riesgos es deficiente, riesgo de captura regulatoria, menor flexibilidad para cambios de política pública.



Doctrina comparada

Tema	Léon Duguit	Gaston Jeze	Maurice Hauriou	Jorge Fernández Ruiz
Definición de servicio público	Toda actividad del Estado	Toda actividad de la administración	Solo una parte de la actividad estatal	Actividad técnica que satisface necesidad general, bajo régimen exorbitante
Naturaleza de la concesión	Contrato administrativo	Contractual	Acto unilateral	Acto mixto con predominio reglamentario
Crisis del servicio público	No aplica	No aplica	No aplica	El servicio público no ha muerto; se ha transformado

APP vs. concesión	No desarrolló	Considera la concesión como servicio público en sentido amplio	Distingue concesión como acto unilateral	Las APP son un nuevo esquema de colaboración que trasciende la concesión tradicional
-------------------	---------------	--	--	--

Legislación aplicable comentada

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 28 CPEUM (facultad de concesionar):

«El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación...»
Base constitucional de todo el régimen de concesiones.

Artículo 115, fracción III:

Catálogo mínimo de servicios públicos municipales (agua potable, drenaje, alcantarillado, alumbrado público, limpia, mercados, panteones, seguridad y tránsito, entre otros).

Artículo 27:

Dominio directo de la Nación sobre los recursos naturales; en materia de hidrocarburos, el propio artículo 28 remite a los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 para la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos como áreas estratégicas.

Leyes secundarias

LFPA, artículo 3:

Elementos y requisitos del acto administrativo aplicables al título de concesión.

Ley General de Bienes Nacionales:

Régimen jurídico para la concesión de bienes de dominio público.

Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP), 2012:

Marco regulatorio de los esquemas APP: objeto y ámbito de aplicación, requisitos de los proyectos, procedimiento de contratación y régimen de ejecución y supervisión.

Reglamento de la LAPP:

Desarrollo de los procedimientos de valoración, licitación y supervisión de proyectos APP.

Esquema de síntesis

I. SERVICIO PÚBLICO

- A. Concepto: actividad técnica que satisface necesidad general, bajo régimen exorbitante
- B. Elementos esenciales: generalidad, igualdad, regularidad, continuidad
- C. Clasificación:
 - 1. Propio / Impropio (por reconocimiento jurídico)
 - 2. Uti singuli / Uti universi (por usuario)
 - 3. Federal / Estatal / Municipal / Concurrente (por jurisdicción)
- D. Formas de prestación:
 - 1. Directa: centralizada, desconcentrada, descentralizada, fideicomiso
 - 2. Indirecta: concesión a particulares
 - 3. Mixta

II. CONCESIÓN ADMINISTRATIVA

- A. Concepto: acto por el cual el Estado confiere a un particular la explotación de un servicio o bien público
- B. Naturaleza: acto administrativo unilateral en México
- C. Elementos: concedente, concesionario, usuario, objeto, título, plazo
- D. Procedimiento: convocatoria → licitación → evaluación → otorgamiento → publicación
- E. Extinción: vencimiento, revocación, caducidad, renuncia, muerte/disolución, nulidad

III. FIGURAS AFINES

- Figura | ¿Derecho preexistente? | Naturaleza
- Concesión | No | Acto unilateral crea el derecho
- Permiso | Sí | Retira obstáculo
- Autorización | Sí | Verifica cualidades
- Licencia | Sí | Verifica conocimientos/habilidad
- Aprobación | Sí | Perfecciona acto previo

IV. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS (APP)

- A. Concepto: colaboración AP + particular para infraestructura y servicios públicos
- B. Marco normativo: Ley de APP (2012) y Reglamento
- C. Elementos:
 - 1. Largo plazo (>10 años, hasta 40)
 - 2. Riesgo compartido público-privado
 - 3. Financiamiento privado
 - 4. Pago vinculado a desempeño
 - 5. Reversión de activos al término
- D. Diferencia con concesión:
 - Concesión: acto unilateral, riesgo privado, tarifa de usuarios
 - APP: contrato, riesgo compartido, pago público/tarifario/desempeño